

1500089-49.2022.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON MORAES CANTEIRO

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra EMERSON MORAES CANTEIRO imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá (SP) - cep 11730-000

1500089-49.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500089-49.2022.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON MORAES CANTEIRO

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra EMERSON MORAES CANTEIRO imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Sustenta a denúncia que, no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 16h, na Avenida Governador Mário Covas Júnior, nº 9471, nesta cidade e comarca de Mongaguá, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 01 porção de maconha, com peso total bruto de 12g e 07 porções de cocaína, com peso total bruto de 18g, conforme auto de exibição/apreensão de fls. 11/12 e auto de constatação preliminar de fls. 13.

Narra que, o denunciado, querendo praticar a traficância ilícita de drogas, trazia consigo as referidas substâncias. Neste contexto, policiais militares que faziam o patrulhamento de rotina no local dos fatos, depararam-se com a presença um indivíduo do sexo feminino e outro do sexo masculino, os quais, notando a aproximação da viatura, subiram em suas respectivas bicicletas e saíram

apressadamente. Os policiais, por sua vez, lograram êxito na captura de ambos, que foram identificados como EMERSON MORAES CANTEIRO, ora denunciado, e Amanda de Paula Gomes. Com EMERSON foram encontradas as referidas substâncias entorpecentes, devidamente embalados para comércio, além de anotações contendo nomes e valores (fls. 36/37), e a quantia de R\$ 30,00. A quantidade de drogas, o local do fato e as atitudes do denunciado, bem como as demais circunstâncias da abordagem indicam que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio espúrio.

À prisão em flagrante se sucedeu a concessão de liberdade provisória (fls. 66/67).

O laudo foi juntado a fls. 111/113.

A denúncia foi recebida (fls. 66/67) e o réu foi citado (fls. 66/67), apresentou resposta à acusação a fls. 78/79.

Em audiência foram colhidas as declarações do ofendido e os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado alega que estava fumando um cigarro de maconha com Amanda e foi abordado pelos policiais, explicando que a droga era para seu consumo pessoal, explicando que as anotações estavam na bolsa que pegou emprestada um dia antes, com seu amigo Rafael, "por estilo".

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da pretensão acusatória, ressaltando a suficiência probatória e o passado criminal e infracional do acusado, com valoração na fixação da pena da reincidência específica e regime inicial fechado. E a defesa técnica, a absolvição do acusado, ante a falta de provas da traficância, subsidiariamente requerendo a fixação da pena no mínimo legal.

Folha de antecedentes e certidão de distribuição estão a fls. 47/49 e fls. 50/52.

Fundamentação

Existência e Autoria

A existência e a autoria delitivas restaram demonstradas pelas provas pericial, documental e oral produzidas.

As declarações dos policiais em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína.

Verdade que a quantidade de droga apreendida não é incompatível com o destino ao consumo próprio de um usuário da droga.

Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros) e de até 0,2g de cocaína, conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP (Hercilio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades, gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010).

Quanto à cocaína, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o uso de 2g de cocaína por mês um dos vetores para a definição de dependência em pesquisa estadunidense que apurou, ainda, consumo médio mensal de 0,8g de cocaína entre todas as 2.349 pessoas que disseram ter consumido a droga entre 1991

e 1993 (Kevin Chen e Denise Kandel, Relationship between extent of cocaine use and dependence among adolescents and adults in the United States, Drug and Alcohol Dependence, v. 68, 2002), mas é subestimada frente ao uso de até 2g a 5g por episódio relatado por 47% de 87 usuários de cocaína atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010), de modo que aquele valor não deve ser tomado de modo absoluto e deve ser sopesado, por exemplo, com o grau de pureza da droga.

Tudo o que se soma à confissão judicial do acusado (artigo 197 do Código de Processo Penal).

Enfim, nestes termos, restaram confirmadas as teses de fato da acusação e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, Epistemologia Judiciária e Prova Penal, RT, 2019, p. 259).

Contudo, não é este o único vetor na análise do dolo, que, no caso, era mesmo a entrega a terceiros, conforme atestado pelas testemunhas, pelas circunstâncias da apreensão, em que nada indica o recente consumo da droga e vem acompanhada de anotações típicas do tráfico, sem olvidar do histórico infracional e criminal do acusado.

O policial militar Vitor disse que sua equipe estava em patrulhamento próximo à plataforma de pesca e, embaixo, havia um casal, Amanda e EMERSON, que, avistando a equipe, se evadiu. Fizeram acompanhamento e, depois, a abordagem, encontrando com EMERSON 7 pinos de cocaína, uma porção de maconha, um papel de anotação com nomes e valores, provavelmente do tráfico, e dois celulares, tudo numa bolsa preta transversal. Foi acionada uma policial feminina que fez busca em Amanda, mas sem encontrar nada de ilícito. EMERSON se negou a declarar qualquer coisa informalmente, mas Amanda chegou a falar que fumaram maconha – embora nada tenha sido encontrado com sinais de uso, apenas embalados para comércio. Encontraram 3 notas de 10 reais. Os dois celulares apreendidos estavam com EMERSON, acha que na bolsa.

O policial militar Gilmar disse que estava em patrulhamento com o Soldado Magalhaes e avistaram EMERSON e outra pessoa embaixo da plataforma de pesca em Mongaguá. Eles subiram na bicicleta e fugiram da equipe. Mais pra frente, fizeram abordagem e encontraram com ele uma bolsa transversal preta com droga dentro. No local, perguntou a EMERSON, mas que nada declarou. Amanda também nada disse.

A propósito do valor do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, realmente, ao que se entende, a presunção de legalidade do ato administrativo não se aplica à esfera penal, norteadas pela estrita presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), devendo a pretensão acusatória ser comprovada em juízo por elementos intersubjetivos.

Em outras palavras, o Estado de Direito exige algo mais para legitimar a privação de direitos do que a palavra dos agentes policiais (v. mutatis mutandis HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), o que está presente no caso concreto consoante os demais elementos de prova já valorados.

Conforme a lição de Aury Lopes Jr., “não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e/ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento.” (Direito Processual Penal, 18ª ed.,

Saraiva, 2021, p. 529).

No caso, a narrativa policial está em consonância com a confissão parcial em juízo e com as circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante.

A este respeito, de se destacar que de todo absurda a tese do acusado, de que desconheceria o conteúdo da mochila que estava transportando e que teria emprestada no dia antes, por questão de estilo. E, como se disse, não se pode ignorar a condenação anterior por delito da mesma natureza, ao que se tornará adiante.

Enfim, nestes termos, restaram confirmadas as teses de fato da acusação e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, Epistemologia Judiciária e Prova Penal, RT, 2019, p. 259).

Adequação Típica

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

Uma vez que o acusado é reincidente, é inaplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, não exigindo a lei que a reincidência seja específica para afastar o redutor.

De qualquer modo, no caso, vê-se que o acusado já havia sido condenado, com trânsito em julgado, por fatos anteriores ao caso vertente, nos autos nº 1500616-69.2020.8.26.0366, crime dos art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com trânsito em 13/09/2021.

Ilícitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça.” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012,

p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. O acusado não ostenta maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, *Fermín Ramírez vs. Guatemala*, julgado em 20/06/2005).

Os motivos do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As circunstâncias, porém, ensejam menor reprovabilidade diante das condições em que havida a apreensão e constatado o destino a terceiros, com o porte de pequena quantidade, de forma simplória, sem notícia de maior envolvimento ou organização criminoso.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas positivamente, diante da pequena quantidade, inferior, até, ao suprimento mensal de um usuário de droga, nos termos já adotados.

Por tudo isto, considero favoráveis a conduta social, as circunstâncias do crime a natureza e quantidade da droga e neutras as demais circunstâncias. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, atribuo peso equivalente a 1/5 para as circunstâncias relativas à natureza e a quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente e 1/6 para as demais, tudo sobre o intervalo de pena em abstrato a cada circunstância favorável e desfavorável. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar, em tese, o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 5 anos de reclusão.

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), deixo de valorar negativamente a reincidência, pois já serviu de critério para o afastamento da causa de diminuição na terceira etapa, evitando-se o bis in idem.

Nada a alterar na terceira etapa, fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs.

Assim, correspondendo a pena-base a 1000 dias-multa, fixo a pena de multa final em 500 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 43 da Lei 11.343/06, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime

inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Diante da condenação a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos e da reincidência, fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Substituição e sursis

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da quantidade de pena aplicada por crime doloso, não preenchido o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Também não cabe a suspensão condicional da pena, fixada em mais de 4 anos, assim independentemente da idade do acusado ou de razões de saúde (artigo 77, caput e parágrafo 2º, do Código Penal).

Efeitos secundários da condenação

Decreto a perda em favor da União, com reversão direta ao Funad, do dinheiro apreendido, produto do crime, nos termos do mandamento constitucional do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do disposto nos artigos 60 a 63 da Lei 11.343/06.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar EMERSON MORAES CANTEIRO à pena de reclusão de 5 anos, em regime inicial fechado, e a 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Não havendo interesse em sua conservação (art. 124 do CPP), encaminhem-se os instrumentos do crime para sua inutilização após o trânsito em julgado.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão, se o caso, e a guia de recolhimento definitiva, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010; comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; e comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal).

Ainda com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, comunicando-se à autoridade policial.

Também após o trânsito em julgado, atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso; expeça-se a competente certidão para execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa).

Comunicado o ajuizamento da execução da multa (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou verificada a prescrição da pretensão executória (evento 22), arquivem-se os autos com a movimentação 61619 no SAJ.

Int.

Mongaguá, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA